SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1088101 - SC (2026/0135320-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	GILBERTO MODOLON SEVERINA
ADVOGADOS	:	FILIPI CORRÊA DE OLIVEIRA - SC051181
		MARIA EDUARDA MARTINS FAVARIN - SC076793
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. ERRO MATERIAL QUANTO À REINCIDÊNCIA DO EMBARGANTE. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA 444/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não decorreu exclusivamente da, então incorretamente reconhecida, reincidência, mas de fundamento autônomo e suficiente extraído do acórdão condenatório: os 22 boletins de ocorrência, a ação penal em curso, a condenação pretérita pelo mesmo delito, ainda que fulminada pela prescrição, e o depoimento de policiais militares no sentido de que o paciente integra organização criminosa evidenciam a dedicação a atividades criminosas, óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado que independe da existência de antecedentes formais.

2. A utilização de tais elementos não se confunde com a exclusiva valoração negativa de antecedentes criminais vedada pela Súmula 444/STJ, na medida em que não se prestam à exasperação da pena-base, mas à aferição do requisito legal atinente à não dedicação a atividades criminosas nem integração à organização criminosa, pressuposto próprio e específico da minorante do tráfico privilegiado.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material apontado.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA59262729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 01:05:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:33
Código de Controle do Documento: f3395c3f-09b5-40b3-b333-4b457e1cfddd

Trata-se de embargos de declaração opostos por **Gilberto Modolon Severina** ao acórdão desta Sexta Turma, de minha lavra, assim ementado (fls. 137/140):

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUALIDADE DA DROGA. QUESTÃO CONTROVERTIDA AO TEMPO DO JULGAMENTO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 REJEITADA PELA REINCIDÊNCIA.
>
> 1. Os Tribunais Superiores firmaram jurisprudência no sentido da inadmissibilidade do *habeas corpus* como substitutivo de revisão criminal.
>
> 2. Não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar concessão de ofício, pois, à época do trânsito em julgado do acórdão condenatório, havia controvérsia jurisprudencial quanto à possibilidade de majoração da pena-base pela qualidade da droga em pequena quantidade, questão posteriormente pacificada no Tema 1.262, o que afasta a qualificação de ilegalidade flagrante.
>
> 3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com a reincidência, situação expressamente impeditiva da minorante, razão pela qual a pretensão defensiva é infundada.
>
> 4. Agravo regimental improvido.

Em suas razões, alega o embargante erro material, pois o acórdão embargado consignou que ele ostenta reincidência, quando, na verdade, a condenação anterior por ele sofrida foi atingida pela prescrição superveniente, o que afastaria a premissa de reincidência utilizada para negar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Aduz, ainda, que a ação penal em curso mencionada no acórdão de origem (Autos n. 0000599-74.2018.8.24.0159) também foi extinta pela prescrição, e que o corréu, este sim reincidente, não se confunde com sua situação pessoal.

Requer o reconhecimento do erro material e, em consequência, a modificação da decisão embargada, com a concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício, para redimensionar a pena mediante a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração comportam acolhimento parcial, sem efeitos infringentes.

Assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material na decisão embargada. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a condenação anteriormente imposta ao ora embargante, nos autos da Ação Penal

Documento eletrônico VDA59262729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 01:05:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:33
Código de Controle do Documento: f3395c3f-09b5-40b3-b333-4b457e1cfddd

n. 0003325-27.2011.8.24.0010, pela prática do crime de tráfico de drogas, foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva estatal, como reconhecido pela própria Corte de origem. A prescrição superveniente à condenação, ao extinguir a punibilidade antes da formação da coisa julgada apta a produzir efeitos penais, impede que esse processo sirva de antecedente para fins de reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, que pressupõe condenação definitiva anterior ao cometimento de novo delito.

Também a ação penal referida nos Autos n. 0000599-74.2018.8.24.0159 não se presta a esse fim, porquanto nela foi reconhecida a extinção da punibilidade do embargante. Dessa forma, a afirmação constante da decisão embargada, no sentido de que a pretensão defensiva seria infundada por se tratar de reincidente, não encontra amparo no acórdão condenatório transitado em julgado, que, ao fixar o regime inicial semiaberto ao ora embargante, expressamente consignou tratar-se de acusado primário. Reconhece-se, portanto, o erro material apontado.

O reconhecimento desse erro, todavia, não conduz à modificação do resultado do julgamento, porquanto **o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não se apoiou exclusivamente na, então incorretamente reconhecida, condição de reincidente do embargante**, mas em fundamento autônomo e por si só suficiente, extraído do próprio acórdão condenatório. Ali ficou consignado que a negativa do redutor decorreu da existência de elementos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, quais sejam, os 22 boletins de ocorrência registrados em seu nome, a ação penal então em curso, a condenação pretérita pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal n. 0003325-27.2011.8.24.0010, ainda que alcançada pela prescrição, e, sobretudo, **o depoimento prestado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, no sentido de que o embargante é conhecido do meio policial pela prática de tráfico de drogas e possui informações do serviço de inteligência que o relacionam à integração de organização criminosa.**

Tais elementos, **considerados em conjunto**, não se destinam a valorar negativamente os antecedentes criminais do agente para fins de exasperação da pena-base, hipótese em que incidiria o óbice da Súmula 444/STJ. Prestam-se, isto sim, à aferição de requisito legal distinto e específico da própria minorante do tráfico privilegiado, que pressupõe, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Cuida-se, como bem pontuou o acórdão de origem, de exceção reconhecida pela jurisprudência à vedação da Súmula 444/STJ, que autoriza a utilização de

Documento eletrônico VDA59262729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 01:05:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:33
Código de Controle do Documento: f3395c3f-09b5-40b3-b333-4b457e1cfddd

inquéritos e ações penais em curso, não para o incremento da reprimenda básica, mas para a demonstração de que o agente não preenche os requisitos cumulativos da causa de diminuição, notadamente quando amparada, como no caso, em prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório acerca da integração a organização criminosa, e não em mera anotação cadastral desprovida de qualquer contexto probatório.

Nesse contexto, a correção da premissa fática relativa à reincidência em nada altera a conclusão de que a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado é infundada, subsistindo hígido o fundamento autônomo consistente na dedicação a atividades criminosas e na integração à organização criminosa, de modo que não se vislumbra a manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, **acolho** os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material apontado, mantendo a condenação do embargante, nos termos fixados pelas instâncias ordinárias.

Documento eletrônico VDA59262729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 01:05:36 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 20/08/2026 06:30:33
Código de Controle do Documento: f3395c3f-09b5-40b3-b333-4b457e1cfddd